

1502804-83.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... suspeita, por ser o local conhecido pelo tráfico, mas não esclareceram quais seriam os dados concretos que justificaria a revista pessoal.

Alem disso, claros ao relatar que mexeram no celular do réu "que estava desbloqueado" e viram mensagens relacionadas ao crime de tráfico.

A par disso, disseram que drogas foram encontradas com o réu, que teria confessado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, . - Jardim Universitário

CEP: 13600-970 - Araras - SP

Telefone: (19)3321-2351 - E-mail: ararascr@tjsp.jus.br

1502804-83.2019.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502804-83.2019.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE MARCO FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal deflagrada para apurar a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, praticado, em tese, por THIAGO DE MARCO FARIA.

O réu foi notificado à fl. 101, e apresentou sua defesa preliminar às fls. 106/109.

A denúncia foi recebida (fls. 126/127) e o réu citado (fl. 167).

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 229/234), em que o Ministério Público requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica.

Agora, conclusos os autos.

É o relatório. DECIDO.

É o caso de trancamento da ação penal.

Com efeito, os policiais militares relataram, em juízo, que estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o réu e realizaram a busca pessoal.

Apesar de mencionarem genericamente a existência de fundada suspeita, por ser o local conhecido pelo tráfico, mas não esclareceram quais seriam os dados concretos que justificaria a revista pessoal.

Alem disso, claros ao relatar que mexeram no celular do réu "que estava desbloqueado" e viram mensagens relacionadas ao crime de tráfico.

A par disso, disseram que drogas foram encontradas com o réu, que teria confessado informalmente, e que, com a autorização de sua genitora, ingressaram em sua residência, e encontraram mais drogas em seu quarto.

Evidente as ilegalidades cometidas.

Em primeiro lugar, não havia justa causa para a revista pessoal do denunciado.

Nesse ponto, conforme prevê o art. 240, §2º, do CPP: "Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

Desta feita, requisito imprescindível à legalidade do ato é a existência de fundada suspeita.

Não podem, os agentes estatais realizarem abordagens indistintas, sem que haja algo que concreto, de palpável a justificar a abordagem de cidadãos, sob pena de violação do princípio da dignidade humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88).

Com efeito, exigir-se a existência, ainda que mínima, de indícios de cometimento de algo ilícito (justa causa) é pressuposto necessário para garantia de direitos fundamentais do indivíduo, tais como aqueles previstos no Pacto de São José, em seus artigos 5º e 11, a saber: direito a integridade física, psíquica e moral; de não sofrer tratamento degradante e de ser tratada com o devido respeito à dignidade inerente ao ser humano, pois "toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade" (art. 11, item 1)

Ninguém olvida que abordagens e revistas policiais configuram, no mais das vezes (e as máximas de experiência apontam nesse sentido), situação de constrangimento, razão pela qual não podem ser aceitas como se lícitas fossem sem que haja substrato fático apto a justificá-las em prol da coletividade, sob pena de ilegalidade.

Assim sendo, resta indubitável que os agentes estatais, balizados que são pelas normas legais, até porque vivemos em Estado de direito, não são livres para revistarem pessoas "a torto e a direito"

Indubitável, porém, que a análise do conceito de "fundada suspeita" comporta certa carga de subjetividade.

De qualquer, conforme adverte o doutrinador Paulo Rangel, "quando a lei se refere a fundadas razões exige que haja um fato concreto autorizador da formação da suspeita. A busca somente será legítima se, efetivamente, houver um dado objetivo, um dado concreto, um fato da vida que autoriza os agentes realizarem a busca e apreensão. O simples olhar do policial, entendendo tratar-se de um carro suspeito ou de uma pessoa suspeita, por exemplo, não pode autorizar a busca e apreensão, sem que haja um dado objetivo impulsionando sua conduta" (RANGEL, Paulo. Direito

Processual Penal, 20a. Edição, editora Atlas, 2012. P. 150).

E mais, continua o nobre autor: "Tornaghi ensina-nos que as fundadas razões que autorizam a busca devem estar lastreadas em indícios fortes de que a pessoa ou coisa procurada encontra-se no lugar da busca" (idem, p. 151)

Buscas realizadas a esmo não são autorizadas por lei. Logo, ilícitas devem ser declaradas.

Nessa linha de entendimento, o E. STJ assim deliberou:

"(...) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...) O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (...) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial." (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz – grifos nossos).

E mais, "O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida" (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz – grifos nossos).

E ainda deve mesmo ser para: "evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;" bem como para "evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural." (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz).

Isso poque: "A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constroem os famigerados "elementos suspeitos" com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela." (STJ, RHC 158580/BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz).

Mas não é só. Verifica-se igualmente como ilegal o acesso a mensagens privadas no celular do denunciado.

Isso porque, a Constituição Federal prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações

telefônicas. Então, a regra é a inviolabilidade. A exceção, é a devassa, que depende de prévia autorização judicial.

Nesse sentido, a CF/88, em seu art. 5º, incisos X e XII, prevê a inviolabilidade da intimidade e vida privada, o sigilo da correspondência e comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, "salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal".

Pois bem, o tema foi regulamentado pela Lei n. 9.294/96, restando evidente a necessidade de decisão judicial fundamentada para validade de interceptação de comunicações telefônicas, de comunicações em sistemas de informática e telemática (art. 1º e 5º).

A inviolabilidade é também prevista na Lei n. 9.472/97, que, ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, prescreve "O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: [...] V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucionais e legalmente previstas" (artigo 3º).

Além disso, como se necessário fosse, a Lei 12.965/14, que estabelece os princípios, garantias e deveres para o uso da Internet no Brasil, prevê que, em seu artigo 7º, que "O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; [...]".

Indubitável, pois, que a devassa em aparelhos celulares apreendidos em operação policial necessita de prévia autorização judicial, sendo ilícita a conduta de alguns policiais de acesso às informações pessoais e, portanto, sigilosas ali existentes.

Assim sendo, o acesso aos dados do celular e às conversas de "whatsapp", com violação à intimidade do agente, sem prévia autorização judicial, deve ser considerado ilegal, não servindo como prova em desfavor do acusado.

Nesse sentido:

"(...). 1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos". (STJ, 6ª Turma, RHC 51531/RO - 2014/0232367-7; de relatoria do Min. Nefi Cordeiro, julgamento em 19 de abril de 2016, DJe 09/05/2016).

Sobre o tema, o STJ fixou os seguintes entendimentos:

"São nulas as provas obtidas por meio da extração de dados e de conversas privadas registradas em correio eletrônico e redes sociais (v.g. whatsapp e facebook) sem a prévia autorização judicial." (RHC 068419/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, Julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016; e, RHC 051531/RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro Julgado em 19/04/2016, DJe 09/05/2016).

E mais:

"É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho

celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (WhatsApp), e obtida diretamente pela polícia, sem prévia autorização judicial." (HC 433930/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª. Turma, Julgado em 19/06/2018, DJE 29/06/2018; REsp 172766/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª. Turma, Julgado em 05/06/2018, DJE 15/06/2018; HC 422299/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª. Turma, Julgado em 24/04/2018, DJE 02/05/2018; RHC 090276/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª. Turma, Julgado em 13/03/2018, DJE 21/03/2018; REsp 1701504/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª. Turma, Julgado em 27/02/2018, DJE 20/03/2018; e, HC 392466/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, 6ª. Turma, Julgado em 12/12/2017, DJE 12/03/2018).

Como se não fossem suficientes para macular todo arcabouço probatório dos autos as ilegalidades acima constatadas, é dos autos ainda a patente nulidade do ingresso domiciliar forçado, sem autorização judicial ou do morador.

Nesse sentido, conforme ensina o mestre E. Magalhães Noronha, "A casa é o asilo inviolável do cidadão"; os ingleses dizem 'My house is my kingdom' (Minha casa é meu reino)." (Curso de Direito Processual Penal, 5a. Edição, editora Saraiva, 1972, p. 93)

Por ser a casa local inviolável, e sendo, porém, permitido o ingresso em situação de flagrância delitiva, a Corte Suprema andou bem ao deliberar, com repercussão geral (Tema 280) quando permitido ingresso por autoridades estatais sem mandado judicial, coibindo-se ações arbitrárias, a saber:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Entretanto, nos autos nada havia de concreto a evidenciar e, portanto, a autorizar o ingresso, de que dentro da casa estava ocorrendo crime em situação flagrancial, tanto que os próprios policiais tentam justificar o ingresso com base em suposta autorização da moradora, genitora do réu.

Todavia, nenhuma prova existe a corroborar tal suposta anuência.

Referida pessoa sequer foi ouvida em solo investigativo e não foi arrolada para oitiva em juízo.

Sem estado flagrancial e sem prova de autorização do morador, o ingresso deve ser tido como ilegal.

Note-se que os elementos dos autos indicam que não houve autorização de ingresso. Nesse sentido, réu e testemunha ouvida em juízo (Rafael) negam que a genitora do denunciado tenha anuído ao ingresso dos policiais.

A simples afirmação dos policiais no sentido de que tiveram autorização do morador, sem que seja por ele confirmada em juízo e/ou perante a autoridade policial (ou por outro elemento idôneo, tal qual gravação ou autorização por escrito), não pode ser considerada válida.

Nesse sentido:

"(...) A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor (...)." (STJ,

6a. Turma, HC 598.051 - SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, em 02 de março de 2021).

Havendo controvérsia acerca da existência da autorização, cabe ao Estado provar sua existência, sob pena de ser tida como ilegal:

“Tráfico de drogas Controvérsia sobre a existência de autorização para ingresso na residência Recente posicionamento do STJ no sentido de que cabe ao Estado comprovar a autorização Prova, nestes autos, inexistente, sendo que a dúvida deve favorecer a Defesa Obtenção de parte da prova por meios ilícitos Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio Reconhecida a ilicitude da apreensão dos entorpecentes encontrados na residência do acusado Desconsideração de tais provas para o exame da conduta do réu Remanesce o fato de ter sido abordado, em via pública, com 2,2g de crack Inexistência de comprovação do intuito de comercialização Desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal Aplicada pena de advertência sobre os efeitos das drogas” (TJSP, 12a Câmara de Dir Criminal, Apelação Criminal nº 1501121-45.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria Des. Amable Lopez Soto, em 08 de julho de 2022).

Resta, assim, evidente ser ônus do Estado a demonstração de que houve prévia autorização para ingresso na residência, que não pode ser admitida válida simplesmente com os depoimentos dos agentes estatais envolvidos na ocorrência.

De fato, da mesma forma que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito” (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472), não deve, por si só, a condição de servidor estatal ser tida como prova incontestável de veracidade de seu conteúdo, sendo imperiosa a análise probatória conglobante, bem como que não agrida as máximas de experiência.

Isso porque, no Brasil, nenhuma prova tem valor absoluto e pré-fixado em lei, não se adotando, ao menos em matéria criminal, o sistema da prova tarifada.

Sobre o tema:

“No Brasil, acolheu-se o terceiro princípio, que é intermediário entre os dois primeiros: o da persuasão racional do juiz, também denominado livre convencimento motivado (...) o juiz apreciará livremente a prova, observando o que consta dos autos, mas ao proferir a sentença, deve indicar os motivos que lhe formaram o convencimento. Não há uma hierarquia das provas. O juiz deve ler os autos, analisar os elementos colhidos e formar livremente o seu convencimento. Porém, este deve fundamentar-se naquilo que esteja nos autos e ser exposto na sentença” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral e processo de conhecimento (1ª parte); 12 a. edição. São Paulo: Saraiva, 2015;. p. 109)

Assim, todas devem ser sopesadas à luz do princípio da persuasão racional, cotejando-as com os demais elementos concretos existentes nos autos, não sendo admissível ainda que ofenda as chamadas máximas de experiência, de forma que testemunhos que atentem ao que ordinariamente acontece não devem ser considerados aptos a fundamentar eventual condenação.

Almejando esclarecer o significado de tal conceito (máximas de experiência) trago à baila decisão proferida pela Corte Suprema do Peru, “in verbis”:

"A máxima da experiência nos diz que um determinado fato, atitude ou fenômeno pode se manifestar de uma certa maneira devido à observação constante e repetida de eventos comuns devido à repetição uniforme de certos eventos da ação

humana". [https://lpderecho.pe/valoracion-prueba-penal-maximas-de-la-experiencia/\(1\)](https://lpderecho.pe/valoracion-prueba-penal-maximas-de-la-experiencia/(1))
- NOTA DE RODAPÉ

E, assim sendo, "contribuem para a formação do convencimento do Juiz através de princípios práticos da vida e da experiência daquilo que geralmente acontece" (Napoleão Nunes Maia Filho, Juiz do TRF-5, citando o Professor João Carlos Pestana Aguiar, em "Comentários ao CPC", vol. IV, RT, São Paulo, 1977, p.103)

Desta forma, tentando ser conciso, nem sempre o testemunho dos agentes estatais deve ser considerado meio idôneo de prova, eis que, quando contrariar os demais elementos dos autos ou as regras de experiência, caberá ao Estado demonstrar, por outros elementos, sua veracidade.

Imaginar-se o contrário importaria dar crédito a afirmações desconectadas da realidade vivida.

Situação exemplar de tal hipótese é a concessão de crédito irrestrito ao depoimento de agente estatal que ingressa em domicílio alheio sem autorização judicial e sem situação flagrancial sob a alegação de que o réu (ou outro morador) o teria autorizado, sem que a acusação traga nenhum outro elemento a evidenciar que, de fato, houve a autorização, tais como documento escrito, gravação, testemunha fora dos quadros policiais, dentre outras.

A ausência de tais elementos outros faz exsurgir, no mínimo, dúvida quanto a real existência de tal autorização e a dúvida favorece o acusado.

Ante o exposto, em razão das ilegalidades já verificadas nos autos e acima mencionadas (revista pessoal sem justa causa, acesso ilegal a mensagens de celular sem autorização judicial e ingresso não autorizado na casa do denunciado), não se vislumbra justa causa para prosseguimento da ação penal em curso, razão pela qual determino o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Expeça-se o necessário.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, bem assim daqueles armazenados para fins de contraprova. Determino a devolução dos valores apreendidos. Oficie-se. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo permitido nesta fase processual.

Determino, ainda, a liberação do celular apreendido, devendo a Autoridade Policial providenciar diretamente a entrega ao seu legítimo proprietário ou representante legal. Caso o bem não seja retirado em até 15 dias pelo legítimo proprietário, fica desde já autorizada a destruição que deverá ser comunicada a este juízo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, providenciando-se as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Araras, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA